

1500975-23.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FOLHA DE ANTECEDENTES, POSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI. REINCIDÊNCIA. BIS IN ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500975-23.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500975-23.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON ANTONIO DE CAMARGO e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

EDSON ANTONIO DE CAMARGO e ROBSON DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, foram denunciados (já computado o aditamento) como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas da denúncia, em ocasião de calamidade pública, subtraíram, para si, 48 produtos de higiene, perfumaria e cosméticos, avaliados em R\$4.000,00, que pertenciam à Drogeria São Paulo.

ROBSON DE OLIVEIRA SILVA foi também denunciado como incurso no artigo 307, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na inicial, em ocasião de calamidade pública, o réu atribuiu a si próprio falsa identidade, para obter vantagem, em seu próprio proveito.

A denúncia foi recebida e o réu Edson foi citado, oferecendo resposta à acusação.

O Ministério Público ofereceu aditamento da denúncia.

Recebido o aditamento da denúncia, os réus foram citados e ofereceram respostas à acusação.

Durante a instrução, foram ouvidas o representante da vítima e as testemunhas arrolada na denúncia. Ao final, foram os réus interrogados.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação, com a condenação do acusado Robson, nos termos da denúncia e seu aditamento, diante da prova produzida, pugnando pela absolvição do corréu Edson, por falta de provas quanto à sua participação no delito. Formulou, por fim, pedidos relativos à dosimetria da pena e fixação do regime prisional.

A Defesa do acusado Edson pugnou por sua absolvição, por falta de provas.

A Defesa do acusado Robson, por sua vez, pugnou pela absolvição, por atipicidade de conduta, com aplicação do princípio da insignificância. Requereu, outrossim, o reconhecimento da tentativa. Pugnou, outrossim, pelo afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública e formulou outros pedidos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade dos crimes descritos na denúncia estão bem comprovadas nos autos, através do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do auto de entrega, do laudo pericial, bem como dos depoimentos colhidos.

A autoria, contudo, somente é certa quanto ao acusado ROBSON.

Interrogado em Juízo, o acusado Robson confessou ter praticado o delito de falsa identidade e admitiu ter praticado o crime de furto contra a drogaria vítima, alegando, porém, ter subtraído apenas três cremes, que teriam sido recuperados pelo estabelecimento comercial quando sairia dele. Disse que havia combinado com Edson, que é taxista, que ele o trouxesse à praia com sua namorada Camila e que, ao final da estada de cinco dias, Edson o buscasse na cidade do Guarujá para levá-lo à sua casa. Contou que, ao final de sua estada, Edson o buscou e, ao passarem por esta cidade de São Vicente, tomaram lanche juntos. Disse que Camila sentiu-se mal e, então, procuraram uma farmácia para a compra de um medicamento. Contou que estava usando uma bolsa pequena e foi com ela à farmácia, mas a fila de atendimento estava grande e desistiu da compra. Disse que viu um creme que usava para tratamento de pele e, então, decidiu pegar três desses cremes e colocou-os em sua bolsa. Alegou que, quando passava pela porta da farmácia, um indivíduo que não estava naquele estabelecimento, mandou que devolvesse os produtos. Disse que, então, entregou àquele indivíduo sua bolsa e dirigiu-se ao veículo de Edson. Contou que nada contou a Edson ou a Camila e apenas pediu que Edson saísse do local, o que ele fez, porém, percorridos cerca de 50 metros, o veículo parou em razão do intenso trânsito e pessoas aproximaram-se gritando “ladrão”. Disse que estavam e frente a uma delegacia e foram abordados. Contou que conhecia Edson como taxista e sempre que precisava deslocar-se o chamava e disse que, naquela viagem, combinou pagar o valor total de R\$300,00 a Edson, porém somente havia transferido o valor de R\$130,00 a ele e não pagou o restante diante de sua prisão. Disse que o veículo de Edson é caracterizado como táxi e possui taxímetro. Contou ter fornecido o nome falso de

Diogo quando estava na delegacia, pois havia sido preso em Brasília e, ao gozar um direito de saída temporária da unidade prisional, para lá não retornou.

O acusado Edson, interrogado em Juízo, negou a prática do crime descrito na denúncia. Disse que trabalha como taxista regularmente na região de Osasco e havia acordado com Robson uma viagem pelo valor de R\$400,00, dos quais recebeu apenas o valor de R\$130,00, antes de serem presos. Declarou que, na data dos fatos, recebeu ligação de Robson, casado com Camila, para buscá-los na praia do Guarujá e assim o fez. Disse que Robson pediu que fizesse o trajeto de retorno pela praia e que parasse em uma lanchonete para comerem. Disse que aceitou tomar lanche com eles e, na saída, Camila sentiu-se mal. Contou que Robson pediu para que fosse a uma farmácia e assim o fez, sendo que Robson desembarcou do veículo dizendo que buscaria o remédio. Disse que Robson permaneceu entre 15 e 20 minutos na farmácia e, ao retornar ao carro, ele disse que havia feito algo errado na drogaria, sem esclarecer o que ele fez, e pediu que fossem embora. Disse que, logo após sair da farmácia, foram abordados por policiais. Contou que Robson não carregava nada consigo quando embarcou no veículo, mas soube que ele havia furtado a farmácia.

O representante da vítima, quando ouvido sob o crivo do contraditório, declarou que estava trabalhando no caixa da drogaria enquanto funcionários da gerência estavam na parte de trás da loja, olhando as câmeras de monitoramento. Disse que viu um indivíduo sair correndo da drogaria e viu também funcionários da gerência correrem atrás dele e soube que estes constataram que aquele havia subtraído alguns produtos da loja. Narrou que foi até a frente da loja e viu que demais funcionários da drogaria foram ao encalço daquele indivíduo, mas não os acompanhou, retornando ao seu posto. Disse que o funcionário que perseguiu o meliante não conseguiu alcançá-lo. Soube que o meliante dispensou produtos subtraídos no chão, conseguindo evadir-se. Esclareceu que não viu o indivíduo que fugiu ingressar em algum veículo e seu colega de trabalho nada lhe disse sobre tê-lo visto entrar em um carro para fugir. Disse que não viu o momento da subtração e também não viu as imagens captadas pelas câmeras de segurança, porém foi designado a ir à delegacia porque a loja estava cheia e com quadro de funcionários reduzido, e o faria apenas para buscar os produtos subtraídos. Declarou que, dentre os produtos que estavam apreendidos na delegacia, havia produtos de sua farmácia, que foram recuperados, mas também havia produtos que não eram da loja em que trabalhava. Consignou que alguns dos produtos que foram apreendidos e levados à farmácia-vítima não pertenciam a ela. Esclareceu que não recordava quais produtos foram subtraídos, nem a quantidade, mas acreditava tratar-se de produtos de beleza. Disse que não realizou reconhecimento do indivíduo detido na delegacia. Consignou que não presenciou a fuga do acusado Robson e não soube se ele portava uma mochila quando evadiu-se. Declarou não ter visto as características físicas do meliante, tendo notado, apenas, que se tratava de um indivíduo magro. Disse não ter visto a pessoa que estava no interior do veículo.

A testemunha policial civil Sérgio Douglas Ribeiro Marques Bento, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que estava no plantão da delegacia quando ouviu pessoas gritando “pega ladrão” e ao sair para a rua, viu a abordagem realizada por um escrivão de polícia e por guardas municipais a um veículo de cor branca, onde havia duas pessoas, sendo elas os acusados. Consignou que, na rua onde estavam, o trânsito era intenso e o veículo havia parado em um semáforo em frente à delegacia, sendo que pessoas que gritavam “pega ladrão” apontavam para o veículo onde os réus foram abordados. Relatou que os acusados, inicialmente, resistiram em sair do veículo e esclareceu que o acusado Edson estava ao volante, enquanto o corréu, cuja identificação naquele momento era Diogo, estava no banco traseiro. Declarou que uma mulher, identificada como Camila, estava em pé ao lado de fora do veículo e foi detida pelos guardas municipais e levada à delegacia para ser ouvida. Narrou que, realizada busca no automóvel, nele foi encontrada uma mochila contendo diversos objetos que, então, soube serem produto de furto praticado contra uma drogaria. Relatou que o representante da vítima compareceu à delegacia, onde reconheceu os objetos apreendidos na mochila como sendo aqueles subtraídos da drogaria,

reconhecendo, também, o acusado cujo nome seria Diogo como sendo o indivíduo que entrou na drogaria para subtrair mercadoria. Consignou que o valor aproximado da mercadoria subtraída era de cerca de R\$4.000,00, sendo a maioria em produtos cosméticos. Disse que, questionados sobre os fatos, os réus nada declararam. Narrou que não manteve contato com Camila, mas soube que, ouvida pelo delegado, ela declarou que estava junto com o namorado “Diogo” e que o acusado Edson era apenas o motorista do veículo. Soube pelo representante da vítima que todos os bens subtraídos foram recuperados e também soube por este que ele não viu o acusado Robson ingressando no veículo dirigido pelo corréu Edson. Narrou que o automóvel abordado não possuía nenhum luminoso que o identificasse como táxi, embora o acusado Edson tenha mencionado ser taxista. Não recordou se a mochila apreendida com mercadorias foi encontrada no porta-malas ou no banco traseiro do veículo. Disse que a distância entre a farmácia e a delegacia era de aproximadamente 50 metros e não soube dizer quanto tempo decorreu entre o furto e a abordagem, esclarecendo que o trânsito estava intenso naquele momento. Não soube dizer se o veículo estava em fuga, pois o trânsito intenso não a possibilitava. Esclareceu que, para sair da farmácia vítima, havia duas rotas e, dependendo de onde o veículo estivesse estacionado, poderia haver deslocamento por vias distintas, ambas com tráfego intenso, porém uma delas não passaria em frente ao plantão da delegacia.

A testemunha policial civil Diego Parada Lopes, ouvida em Juízo, narrou que estava nos arredores da delegacia quando ouviu gritos vindos da rua e, na parte externa, identificou que pessoas gritavam “pega ladrão”, apontando para um veículo táxi, de cor branca. Disse que, realizada a abordagem, verificou-se que o acusado Edson estava ao volante. Consignou que, no veículo, estava também o corréu e uma mulher, que desembarcou do automóvel e não foi abordada naquele momento. Declarou que, em busca veicular, foi apreendida uma mochila contendo produtos de perfumaria, higiene e cosméticos diversos, além de documentos da mulher que havia desembarcado. Não recordou em que local do veículo estava a mochila apreendida. Relatou que os acusados foram conduzidos à delegacia e, posteriormente, a mulher que havia saído do automóvel retornou aos arredores da delegacia e acabou por ser para lá conduzida. Narrou que um dos acusados forneceu nome falso, mas não recordou qual deles assim agiu, nem qual o nome declarado. Consignou que manteve contato com o acusado Edson na delegacia e este, inicialmente, declarou ser motorista de táxi, dizendo que havia sido solicitado pelo casal para realizar uma corrida, sem saber o que havia ocorrido, mas não informou de que forma havia sido acionado para a viagem. Relatou que o representante da vítima foi à delegacia, onde reconheceu os bens apreendidos na mochila como sendo aqueles subtraídos. Soube pelo representante da vítima que, na farmácia, ele havia notado que o acusado, identificado como “Diogo”, havia subtraído algumas mercadorias do local e, ao lado de fora, viu “Diogo” embarcar em um veículo de cor branca, sendo que este veículo foi seguido por alguns populares e acabou parando em um semáforo defronte à delegacia. Declarou que a farmácia está situada em local próximo à delegacia e não soube se populares foram avisados sobre o furto pelos funcionários da farmácia. Disse que as pessoas indicavam o veículo de cor branca. Declarou não recordar se o veículo possuía o sinal luminoso de táxi, porém ele possuía um taxímetro, que não recordou se estava ou não ligado. Soube que Camila estava, inicialmente, dentro do veículo, porém, durante o alvoroço diante da delegacia, Camila conseguiu sair do veículo, o que foi noticiado por populares. Esclareceu que não houve notícia de que Camila tenha sido vista dentro da farmácia, nem mesmo Edson foi visto dentro daquele local. Não soube se o veículo onde estavam os acusados estava em fuga ou se estava transitando normalmente na via. Disse que não conhecia os réus anteriormente aos fatos.

Em face de toda a prova carreada aos autos, diante do relato do representante da vítima e das testemunhas policiais civis, os quais foram fornecidos com segurança e detalhes, e que corroboraram a confissão do acusado Robson em Juízo no que tange à autoria dos crimes, não há dúvidas em se concluir que este efetivamente praticou o delito de furto e também o delito de falsa identidade descritos na denúncia.

Embora a confissão não seja prova dotada de caráter absoluto, no presente caso, quanto à autoria do crime, ela está em conformidade com os demais elementos coligidos aos autos, tendo sido confirmada pelos depoimentos judiciais do representante da vítima e dos policiais civis que realizaram sua prisão em flagrante.

Note-se que, embora o representante da vítima tenha declarado em Juízo não ter visto o acusado efetuado a subtração da mercadoria no interior da farmácia, declarou ter visto uma pessoa sair correndo de dentro da drogaria, sendo seguida por funcionários da loja que haviam constatado que aquela havia furtado produtos.

Asseverou, ainda, o representante da vítima que foi à delegacia, onde reconheceu os objetos apreendidos como sendo da loja, esclarecendo que, dentre os produtos, havia alguns que não pertenciam ao comércio em que trabalhava.

Já as testemunhas policiais civis consignaram que ouviram gritos de populares que apontavam para um veículo branco e noticiavam ter ocorrido um crime, sendo que, realizada a abordagem e feita a busca no automóvel, nele foi encontrada uma mochila contendo diversas mercadorias, que foram reconhecidas pelo representante da vítima como sendo de propriedade da drogaria.

Dessa forma, o crime de furto e sua autoria, com relação ao acusado Robson, restaram bem demonstrados nos autos.

Pelos elementos constantes dos autos e diante do consolidado entendimento dos Tribunais Superiores que prestigia a Teoria da Apprehensio, verifica-se que o furto foi consumado, uma vez que o acusado Robson conseguiu apoderar-se da res, invertendo a posse, independentemente de ter sido esta tranquila, mansa e pacífica.

Incide na espécie o Enunciado da Súmula nº 582 do E. Superior Tribunal de Justiça: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

Consigne-se que, ao contrário da versão fornecida pelo acusado Robson em Juízo, de que somente três produtos foram por ele subtraídos e dispensados na saída da drogaria, realizada a busca no veículo, foram encontrados em uma mochila 48 itens de produtos cosméticos e de perfumaria, que foram apreendidos e reconhecidos pelo representante da vítima como sendo produtos da loja.

Assim, em que pese as declarações do representante da vítima de que, dentre todos os objetos apreendidos, havia alguns que não pertenciam à drogaria, é certo que, efetivamente, houve a subtração de mercadorias, com a retirada destas do interior da loja, e elas somente foram recuperadas em local distante da loja-vítima, diante da ação policial, que atendeu ao alerta dado por populares.

De outra banda, não há nos autos elementos suficientes para embasar a condenação do acusado Edson.

Depreende-se da prova colhida em Juízo que o acusado Edson não foi visto pelo representante da vítima no interior da drogaria. Note-se que o representante da vítima também não viu o corréu Robson ingressar no veículo de Edson ao sair da farmácia, nada esclarecendo sobre eventual fuga empreendida por Edson quando na direção do automóvel.

Da mesma forma, as testemunhas policiais ouvidas nada puderam esclarecer acerca da participação do acusado Edson na empreitada criminosa, tendo relatado apenas que Edson declarou-se taxista na ocasião de sua abordagem.

Veja-se que as testemunhas policiais, da mesma forma, não esclareceram se o corréu Edson conduzia seu veículo como se estivesse em fuga, de um lado porque não presenciaram o momento em que o acusado Robson saiu da farmácia logo após o furto e ingressou no veículo e, de outro lado, porque, conforme suas declarações, o tráfego estava intenso naquele momento e a rápida dispersão não seria possível.

Assim, em relação ao acusado Edson, para se lançar uma condenação, é imprescindível a certeza ampla de ser ele coautor do crime ou ter ele concorrido para o crime que lhe foi atribuído. Se houver qualquer dúvida no espírito do julgador, a absolvição é medida que se impõe, porquanto a liberdade de uma pessoa não pode ser coarctada sem que a acusação seja comprovada por provas exatas e seguras.

Frise-se que sua inocência não é patente.

Todavia, diante desse quadro probatório e havendo sérias dúvidas no que pertine à participação no crime descrito na denúncia, a absolvição de Edson é medida que se impõe, pois antes absolver provável culpado a condenar inocente.

Por consequência lógica, a qualificadora do concurso de pessoas relativa ao crime praticado pelo acusado Robson deve ser afastada. Repise-se que nem o representante da vítima, nem mesmo as testemunhas policiais civis, puderam esclarecer se, efetivamente, houve a participação do corréu Edson na execução do crime.

Por fim, em que pese ao entendimento da Defesa, não cabe a aplicação do princípio da insignificância no presente caso.

Para a aplicação do princípio da insignificância, não basta apenas aferir o pequeno valor da res. Sua aplicação deve ser feita com certas restrições, principalmente, no que se relaciona à delimitação do que a sociedade tolera de fato ou do que seja um crime insignificante. Não se pode abrir espaço para delitos comprometedores da ordem social, mesmo sendo pequenos.

Há que se considerar vários critérios, dentre eles, o desvalor da ação.

O réu, no presente caso, decidiu ingressar em uma farmácia, em local movimentado, em plena luz do dia, para de lá subtrair mercadorias.

Tal conduta é totalmente reprovável, não se podendo aceitar que sejam toleradas pela sociedade, ainda que o bem furtado seja de pouca significância.

Além disso, o acusado possui maus antecedentes e é reincidente.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (HC-106292 /MG, DJe-024, 07.02.2017).

Nesse mesmo sentido:

“(...) 4. O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. 5. O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal. 6. Ordem

denegada.” (HC 102088/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 20/05/2010)

Dessa forma, não é caso de aplicação do princípio da insignificância em face do desvalor da ação do acusado.

Desta maneira, restou provada a prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Quanto ao crime previsto no artigo 307 do Código Penal, como já exposto, a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, bem como pelos documentos de fls. 177/180.

Há, da mesma forma, prova suficiente acerca do delito de falsa identidade.

O réu, quando detido, identificou-se como Diogo Augusto de Araújo Melo.

Quando interrogado em Juízo, admitiu que assim agiu porque não retornou à unidade prisional em que se encontrava após uma saída temporária.

Verifica-se que a verdadeira identidade do acusado não foi de plano revelada, o que somente ocorreu quando a unidade prisional em que ele se encontrava detido informou haver legitimação junto ao IIRGD, que indicava o verdadeiro nome de Robson (fls. 177/180).

Há, portanto, prova suficiente da prática do delito tipificado no artigo 307 do Código Penal.

Parcialmente procedente a denúncia, passo, portanto, a dosar a pena.

Quanto ao crime de furto, atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é detentor de maus antecedentes (informação de fls. 270/273 da folha de antecedentes), motivo pelo qual aumento a pena-base em 1/6, a qual resta fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor de cada dia-multa no mínimo legal, devendo ser corrigido desde a data dos fatos.

Na segunda fase da aplicação da pena, observo que o réu é reincidente pela prática de mesma espécie de delito (informação de fls. 265, 270 e 273 da folha de antecedentes, referente ao Processo de nº 8977/14 da 2ª Vara Criminal de Diadema). Imponho, portanto, um aumento de 1/3 em sua pena, a qual resta fixada em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor já fixado.

Frise-se que a falta de certidão criminal (certidão de objeto e pé) não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, o que pode ser feito pela folha de antecedentes. Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FOLHA DE ANTECEDENTES, POSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Não é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir pela inocência da paciente em relação ao delito que lhe foi imputado, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, diante da celeridade do seu rito procedimental, notoriamente marcado pela ausência de dilação probatória. 3. Esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado no

sentido de que a folha de antecedentes criminais é documento hábil à comprovação da reincidência. 4. Para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, faz-se necessário o preenchimento de todos os requisitos previstos na lei (ser o réu primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa), não caracterizando bis in idem a utilização da reincidência pelo Juiz sentenciante para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e para agravar a pena, ante previsão legal. 5. Writ não conhecido" (STJ HC 211072/MS Relator Min. Sebastião Reis Júnior J. 26/11/2013.) (g.n.)

Verifico, ainda, que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/6, ficando ela fixada em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor já estabelecido.

Não é possível o reconhecimento da confissão espontânea no presente caso, em relação ao crime de furto, pois foi parcial, e feita com o nítido objetivo de se beneficiar com tipificação mais branda para sua conduta. Note-se que o acusado, ao admitir ter subtraído mercadorias da farmácia, declarou ter-se apossado de apenas três itens, que dispensou ainda na área da drogaria, ao ser abordado por uma pessoa na saída, versão esta que restou isolada no contexto probatório.

Como ensina Mirabete, não basta "a simples confissão para que se configure a atenuante; exige a lei que ela seja espontânea, de iniciativa do autor do crime, e que seja completa e movida por um motivo moral, altruístico, demonstrando arrependimento" (in Código Penal Interpretado, 5ª ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2005, p. 517).

Nesse sentido:

"CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE - Confissão espontânea parcial - Reconhecimento - Impossibilidade: - A confissão parcial, imbuída de maliciosa negativa de circunstâncias agravantes, não dá lugar à incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do CP." (Apelação nº 1.170.253/9 - São Paulo - 7ª Câmara - Relator: Corrêa de Moraes - 3/2/2000 - V.U.)

"Em se tratando de atenuante da confissão, o agente que buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação das penas, confissão pela metade". (RJTACRIM 33/56)

(...) Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - Impossibilidade - Confissão parcial externada pelo réu com o intuito de se eximir de responsabilização criminal (...). (TJSP, 0004729-51.2015.8.26.0129, Relator(a): Juvenal Duarte; Comarca: Casa Branca; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 01/12/2016; Data de registro: 05/12/2016);

(...) Confissões parciais. Reconhecimento da atenuante. Impossibilidade. (...). (TJSP, 0000441-82.2015.8.26.0542, Relator(a): Luiz Fernando Vaggione; Comarca: Carapicuíba; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/01/2017; Data de registro: 18/01/2017);

(...) Confissão parcial que não tem o condão de atenuar a reprimenda (...). (TJSP, 0003652-50.2015.8.26.0050, Relator(a): Cesar Mecchi Morales; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/01/2017; Data de registro: 18/01/2017).

Na última fase do cálculo da pena, não há causas de aumento e de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Torno essa pena definitiva na ausência de modificadoras.

Quanto ao crime de falsa identidade, atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui maus antecedentes, na forma como já exposto, motivo pelo qual aumento a pena-base em 1/6, a qual resta fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase da aplicação da pena, observo que o réu é reincidente, conforme também exposto. Imponho, portanto, um aumento de 1/6 em sua pena, a qual resta fixada em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Verifico, ainda, que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública, circunstância esta que deve ser reconhecida, de acordo com a fundamentação já referida. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Contudo, reconhecida, quanto ao delito de falsa identidade, a circunstância atenuante relativa à confissão espontânea, ficam estas circunstâncias compensadas.

À míngua de outras causas de modificadoras, torno essa pena definitiva.

Oportuno esclarecer que, embora o caso concreto reflita condenação por um crime apenado com reclusão e outro apenado com detenção, o regime deve mesmo ser unificado para fins de determinação do regime inicial, como, aliás, vem decidindo o C. STJ, nos seguintes arestos:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE AMEAÇA, PORTE ILEGAL DE ARMA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSORÇÃO DO CRIME MENOS GRAVE PELO MAIS GRAVOSO. CRIMES AUTÔNOMOS. MOMENTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 14 E 15 DA LEI N. 10.826/2003. MOMENTOS DISTINTOS. INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DO JULGADO SEGUNDO A PRETENSÃO DA DEFESA. INDISPENSABILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. MEDIDA INTERDITADA NO ÂMBITO DO REMÉDIO HEROICO. REGIME INICIAL. CONCORRÊNCIA DE PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMA A ULTRAPASSAR QUATRO ANOS. MODO INTERMEDIÁRIO. REGRAMENTO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

VI - Regime inicial. Concorrendo penas de reclusão e detenção, sendo possível a aplicação do regime inicial aberto para ambas, na hipótese em que o somatório delas ultrapassar 4 (quatro) anos, é cabível a aplicação do regime inicial semiaberto. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no HC n.502.549/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/08/2019; e AgRg no HC n. 578.884/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 09/03/2021. Assim, a despeito da existência de circunstâncias judiciais favoráveis e da primariedade do paciente, o quantum de pena aplicado reclama o modo intermediário, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do

Código Penal. Agravo regimental desprovido" (AgRg no Habeas Corpus n. 664.602, rel. Min. Félix Fischer, 5ª T., j. 01/06/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE 8 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DOS DELITOS INSCRITOS NOS ARTS. 288 DO CÓDIGO PENAL E 90 E 96, INCISO IV, DA LEI N. 8.666/1993, C/C OS ARTS. 29, 69 E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)

5. O agravante foi condenado a uma pena de reclusão de 2 anos e 3 meses e a uma pena de detenção de 6 anos e 6 meses, o que totalizou uma pena de 8 anos e 9 meses. 6. O art. 111 da Lei de Execuções Penais dita que, "quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição". 7. Assim, concorrendo penas de reclusão e detenção, originadas da pluralidade de condenações, o somatório de ambas determina o regime inicial de cumprimento da pena, inexistindo qualquer ilegalidade no acórdão da origem ou na decisão recorrida. 8. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no Habeas Corpus n. 479.519, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 14/09/2021)

As penas dos crimes, portanto, deverão ser somadas de acordo com as regras do concurso material de delitos, totalizando 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor já estabelecido.

Considerando as peculiaridades do presente caso e as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, observando-se que o acusado é portador de maus antecedentes, além de ser reincidente específico quanto ao crime de furto, fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena, diante da reincidência do réu, bem como é incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria bem demonstradas – Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa – Ré confessa, ademais – Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos – Precedentes – Pena de multa que se corrige – Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante – Regime fechado justificado – Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito – Detração – Matéria afeta ao Juízo das Execuções

Criminais – Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

1. CONDENAR o réu ROBSON DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, incidente a correção monetária, por infração ao disposto nos artigos 155, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", e artigo 307, na forma do disposto no artigo 69, todos do Código Penal, ficando estabelecido o regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 111 da Lei de Execuções Penais.

2. ABSOLVER o réu EDSON ANTONIO DE CAMARGO, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita de ter praticado o delito previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, o que faço com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nego ao réu ROBSON o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. O acusado é reincidente específico pelo crime de furto e as circunstâncias judiciais lhe são negativas, pois é portador de maus antecedentes. A reiteração de condutas criminosas evidencia a dificuldade do réu em aceitar a ordem legal estabelecida, pois não hesita em reiterar prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social.

Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição.

Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Ausente demonstração mínima dos integrais prejuízos sofridos pela vítima, bem como pela ausência de pedido nesse sentido, deixo de condenar o réu nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do direito de reparação do ofendido a ser perseguido na esfera cível.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 28 de julho de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA